

1501449-73.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso. Nessa senda: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1501449-73.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501449-73.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK MARLEY GERMANO CAVALCANTI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos

ERIK MARLEY GERMANO CAVALCANTI e MÁRCIO ROBERTO DO NASCIMENTO DE JESUS foram DENUNCIADOS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c artigo 29, do Código Penal, porque no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 16h06, na Rua Inocêncio Lazarino, nº 270, Jardim Bom Jesus, nesta cidade e Comarca de Tremembé/SP, transportavam 09 (nove) porções de maconha, com peso líquido de 266,37g (duzentos e sessenta e seis gramas e trinta e sete decigramas) e 120 comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.76/79).

Determinada a prisão preventiva dos acusados em audiência de custódia (fls. 52/61).

Defesas prévias (fls. 180/185) e (fls. 197/198).

Denúncia recebida (fls. 207/208).

Alvará de soltura de Marcio (fl. 303) e de Erik (fl. 307).

Audiência de instrução, onde foram ouvidas três testemunhas e interrogados os acusados (fls. 355/357).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, opinando sobre a dosimetria da pena.

A defesa pugnou pela absolvição dos acusados. Subsidiariamente, a defesa de Erik

pugnou pela desclassificação do delito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A representação é PROCEDENTE.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 15/17), laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/118), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte dos acusados, senão vejamos:

A testemunha Maycon Willian dos Santos relatou que estava em patrulhamento pela cidade de Tremembé/SP quando avistou os dois indivíduos a pé e, em razão do nervosismo deles realizaram a abordagem. Em revista pessoal foi encontrada uma chave no bolso de Erik, que indicou onde estava o Veículo. Erik disse que o veículo, confessando existir entorpecente no automóvel. No veículo foi localizado lança perfume e LDS. Erik confessou que tinha mais drogas em sua residência, droga que fornecia em festas rave. Na residência de Erik foram localizados mais entorpecente "LSD e maconha fracionada". Na Casa do acusado Marcio nada foi localizado. Marcio confirmou o relato de Erik, aduzindo que participava das festas e auxiliava Eric na promoção das festas. Questionado, o depoente afirmou que participou da abordagem e da revista nas casas, sendo o condutor da ocorrência. Estava em moto. Márcio disse que promovia festas, mas não confessou sobre os entorpecentes, sendo somente Erik que confessou sobre os entorpecentes.

A testemunha Wilson de Barros Junior disse que estava em patrulhamento, quando avistaram os acusados próximos a um posto de gasolina, demonstrando nervosismo. No bolso de Eric foi encontrado uma chave, sendo que o acusado apontou onde estava o veículo. No automóvel foi localizado entorpecente. Os acusados disseram que tinha sociedade em festa rave. Na residência de Eric foram localizadas mais drogas em seu quarto e cartões de crédito. Não se recorda de encontrar máquina de cartão de crédito. Alguns cartões estavam em nome de Eric, alguns em nome de terceiros e alguns sem nomes. Sobre Marcio, nada de ilícito foi encontrado em sua residência. Marcio Roberto disse que agia em sociedade tanto na compra como na comercialização do entorpecente, que vinha de São Vicente, e era revendida em festas raves. A abordagem foi junto com Maicon. Questionado sobre a oitiva dos acusados, o depoente informou que a praxe policial é separar as partes para ver se entram em contradição. Conversou com os dois acusados. Eles não foram divergentes em seus depoimentos. Acredita que Maicon ouviu a mesma coisa.

A testemunha Aracy, avó de Erik, informou que os policiais efetuaram buscas no quarto de Erik. Seu Marido acompanhou a busca. Não autorizou nada, mas quando perguntaram se podiam olhar o quarto autorizou, quando pediram para olhar o carro também autorizou. Quando chegou no quarto viu o policial com uma sacolinha e perguntou o que era, sendo informada que era maconha e balinha. A depoente relata que criou Erik, que trabalhava com seu marido. Ultimamente Erik estava trabalhando na adega. Erik frequentava muitas festas, quase todos os dias. Não sabe se ele organizava as festas. Sabe que ele ganhava pouco, mas dava pra gastar só com ele. Interrogada em juízo, o acusado Marcio disse que na data do ocorrido estava com Eric, mas não tinha ciência das drogas. Viu o galão com líquido no automóvel, mas acreditava ser gasolina. Conhece Eric há dois anos. Não frequentava as festas, ficava mais na adega, onde trabalhava e indicou Erik para trabalhar. Não sabia do envolvimento de Erik com drogas, se soubesse teria se afastado para não acontecer o que aconteceu. No dia dos fatos, foi até a casa de Eric, pois iam sair para almoçar. Pararam no posto pra pegar uma coca e aconteceu isso. Trabalha como digital influencer e cobra para divulgar festa em seu instagram.

Interrogado em juízo, o acusado ERIC confessou os fatos. Disse que na data dos fatos o conduziram até sua residência. Foi abordado por uma Spin. Quando estava em sua residência começou a chegar viaturas da ROCAN. Na data não assumiu a venda dos entorpecentes, porque o entorpecente era para uso pessoal e de Marcio. O policial que se apresentou como testemunha não foi o mesmo que fez a abordagem. O local da abordagem é diverso do indicado nos autos. Não acompanhou a busca no carro.

Confessa a posse da droga. Estava com a droga para fins de consumo, para o depoente e Márcio. Os dois consumiriam os 120 comprimidos. Nunca foi preso por nenhum crime.

É usuário de drogas. Está fazendo tratamento junto ao CAPS. Sobre os três litros de lança perfume usaria como desoxidante. Fazia faculdade de biomedicina, e tem bastante festa. Pagou R\$ 750,00 pelos 120 comprimidos de êxtase. O comprimido saía a partir de 07 reais a unidade, em grande quantidade caía o preço. Os amigos que iam com ele também consumiam. Ganhava salário mínimo fixo mais comissão por cada obra que fechava e tinha uma lojinha no instagram. Todas as atividades rendiam mais ou menos uns 2.500 por mês.

As versões apresentadas pelos acusados são conflitantes e divergentes entre si. Enquanto Marcio afirma que desconhecia a prática de tráfico de entorpecentes praticada por Erik, Erik afirma que os dois eram usuários e adquiriram o entorpecente para consumo pessoal.

Não obstante a fala contraditória, evidente que as partes estavam envolvidas com o objetivo de lucrar com o entorpecente encontrado, que se destinava a abastecer as festas promovidas e frequentadas por ambos.

Ressalte-se que a quantidade de entorpecente localizado em poder dos acusados era significativa, sendo três litros de matéria prima para produção de drogas, bem como 120 comprimidos de êxtase, droga sintética, amplamente consumida em festas raves, além de maconha.

Além do mais, a natureza das substâncias, a forma de acondicionamento, bem como a quantidade, demonstra a finalidade da comercialização.

Como informado pelo próprio Erik, a substância êxtase tem relevante valor comercial. Ademais, Erik confessa que fornecia drogas, ainda que forma gratuita, para seus amigos que frequentavam as referidas festas.

Corroborando com o todo evidenciado nos autos, a avó de Erik relata que o neto não ganhava muito, mas tinha uma rotina de saídas quase diárias para frequentar as famosas festas raves, de forma que a traficância certamente vinha sustentando seu estilo de vida.

Informalmente, Marcio confirmou para a testemunha Wilson que auxiliava Erik, mantendo uma espécie de sociedade, o que fica devidamente demonstrado pela divulgação dos eventos em seu instagram.

Portanto, reitero que a versão dos acusados, além de dissonante é isolada nos autos e diverge do todo coligido nos autos.

No mais, o depoimento dos policiais foi coeso no sentido de afirmar que o entorpecente foi encontrado no automóvel junto com os acusados tinha como destino a comercialização.

Convém frisar, nesta oportunidade, que: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286).

Nesse sentido, ainda: “Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição” (RT 614/275).

Cumpra salientar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: “O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJ/RS, Apelação n.º 697.020.717, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633). “Tóxico - tráfico - Quantidade significativa encontrada em poder do réu que o caracteriza, além de usuário, como traficante - Recurso não provido” (Apelação Criminal n.º 241.145-3 - Guarujá - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 06.08.98 - V.U.).

Com isso, reconheço que as negativas dos réus em relação à prática do tráfico de entorpecentes restaram isoladas nos autos.

De rigor, portanto, a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas. Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, passo à fixação da pena.

Em relação à pena base, em virtude da natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base para os acusados deve ser fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes para ambos.

Na terceira fase, sem causa de aumento de pena. Aplicável, entretanto, para ambos acusados, a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, considerando que são primários, mantém bons antecedentes e trabalhavam.

Todavia, não aplicável no patamar máximo, diante da natureza e quantidade de entorpecentes encontrados. Assim, fixo a pena em definitivo em 03(três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial de pena em aberto.

Ademais, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que não foram preenchidos integralmente os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ERIK MARLLEY GERMANO CAVALCANTI e MÁRCIO ROBERTO DO NASCIMENTO DE JESUS, qualificados nos autos, à pena de 03(três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Transitada em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Intime-se os réus para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais devidas (100 UFESP'S).

Tendo sido o réu defendido por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários ao(à) defensor(a) dativo(a) atuante nos autos, observado o código 302.

Em relação à droga apreendida, ante o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial para imediata destruição, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006, ou comunicação nos termos do artigo 525 das NSCGJ.

P.I.C.

Tremembe, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA